

<제01장 행정소송의 일반론.제02절 행정소송의 유형>

[예상][1.02-1]인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

《【문제1.2】

<사례>

A시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음1) 甲이 제기하고자 하는 `예방적 금지소송`이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 관련하여 우리 판례의 입장을 서술하고, 만약 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명하라.》

<문제1.2의 물음1> 인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 자신의 주거지 인근에 화장장 건립계획이 확정·발령되기 전에 그 시행을 금지하여 달라는 소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송이 현행 행정소송법상 허용되는지> 여부와 <허용되지 않는 경우 甲이 취할 수 있는 다른 권리구제수단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명한다.

II. 예방적 금지소송의 허용 여부

1. 예방적 금지소송의 의의

- 예방적 금지소송이란 행정청이 장래 일정한 처분을 할 것이 예상되는 경우에 미리 법원에 그 처분을 하여서는 안 된다는 명령을 구하는 소송을 말한다. 이는 행정권의 남용으로 인한 회복하기 어려운 손해를 미연에 방지하고자 하는 취지에서 논의된다.

2. 학설의 태도

(1) 긍정설

- "행정소송법 제4조"의 항고소송 열거를 예시적인 것으로 보아, 국민의 재판청구권을 실질적으로 보장하고, 실효성 있는 권리구제를 위해 명문의 규정이 없더라도 예방적 금지소송을 인정해야 한다는 견해이다.

(2) 부정설

- "행정소송법 제4조"는 항고소송의 종류를 한정적으로 규정한 것이며, 예방적 금지소송을 인정할 경우 행정권의 1차적 판단권을 침해하여 권력분립 원칙에 반하게 된다는 견해이다.

3. 판례의 입장

- 우리 "대법원"은 예방적 금지소송에 대하여 매우 엄격한 부정적 입장을 견지하고 있다. "판례"는 행정소송법상 항고소송의 종류는 법에 명시된 것에 한정된다고 보며, 행정청의 처분이 내려지기 전에 미리 그 처분의 금지를 구하는 소송은 현행법상 허용되지 않는다고 판시한다.

(1) 판결의 주요 논거

- "대법원"은 행정처분에 대한 사법심사는 행정청이 처분을 발령한 이후에 그 적법성을 판단하는 것이 원칙이라고 본다. 만약, 처분이 발령되기도 전에 법원이 이를 금지한다면 행정청의 고유한 권한을 사전에 제약하게 되어 권력분립의 원칙상 부당하다는 점을 강조한다.

(2) 구체적인 사례

- "판례"는 화장장 건립 반대나 건축 허가 금지 청구 등과 같이 장래의 처분을 미리 저지하려는 청구에 대하여 소의 부적법을 이유로 각하판결을 내리고 있다. 즉, 주관적 권리구제의 필요성보다 행정의 자율성과 사법부의 사후 심사 원칙을 우선시키고 있다.

III. 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형 및 구제 수단

1. 처분 발령 이후의 항고소송

- 예방적 금지소송이 허용되지 않으므로 甲은 행정청의 화장장 건립 계획이 대외적으로 확정되어 처분의 형태로 발령될 때까지 기다려야 한다.

(1) 취소소송

- A시장의 화장장 건립 결정이 처분성을 갖추어 발령되면, 甲은 해당 처분이 자신의 법률상 이익을 침해함을 근거로 처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다. 이는 "행정소송법 제4조 제1호"에 따른 가장 전형적인 항고소송이다.

(2) 무효확인소송

- 만약, 해당 건립 계획 처분에 중대하고 명백한 하자가 존재하여 그 효력이 처음부터 발생하지 않았다고 판단되는 경우에는 무효확인소송을 제기하여 그 효력 유무를 다툴 수 있다.

2. 가구제 수단의 활용(집행정지)

- 사후적 소송만으로는 이미 진행된 공사 등으로 인해 甲의 권익이 침해될 위험이 크다. 따라서 본안 소송 제기과 동시에 집행정지를 신청하여 실효성을 확보할 수 있다.

(1) 집행정지의 요건

- 甲은 취소소송 또는 무효확인소송을 제기한 상태에서, 처분의 집행이나 효력의 정지가 없으면 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고, 긴급한 필요가 있다는 점을 소명해야 한다.

(2) 집행정지의 효과

- 법원이 甲의 신청을 인용하여 집행정지 결정을 내리면, 본안 판결 시까지 화장장 건립 계획의 효력이나 그에 따른 공사 집행이 일시적으로 정지된다. 이는 예방적 금지소송의 실질적인 대안 역할을 한다.

IV. 사안의 적용

- 사안에서 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송은 "판례"에 따르면 현행 행정소송법상 허용되지 않는다. 따라서 甲이 계획 단계에서 제기하는 금지소송은 각하될 가능성이 크다.

1. 소송의 부적법성

- 甲의 청구는 행정청의 1차적 판단권을 침해하고, 법적 근거가 없는 소송 유형이므로 “판례”상 부적법하다.

2. 대안적 권리구제

- 甲은 화장장 건립 계획이 처분으로서 발령된 직후에 취소소송을 제기해야 한다. 또한, 처분의 효력을 즉시 멈추기 위해 집행정지를 신청함으로써 건립 중단이라는 실질적인 목적을 달성할 수 있다.

3. 관련 이익의 검토

- 甲은 인근 주민으로서 환경상 이익 등 법률상 이익을 가지는 제3자에 해당하므로 원고적격을 인정받는 데 어려움이 없을 것이며, 처분 발령 후 적법한 기간 내에 소를 제기해야 한다.

V. 결론

- 결론적으로 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송은 우리 “판례”상 허용되지 않는다. 甲은 향후 행정청이 건립 계획을 처분으로 발령하면 그에 대하여 취소소송을 제기하고, 이와 병행하여 집행정지 신청을 함으로써 권리를 구제받아야 한다. 이러한 “판례”의 태도는 행정의 능동적 수행을 보장하기 위한 것이나, 국민의 권익 보호를 위해 향후 행정소송법 개정 등을 통해 예방적 금지소송의 도입을 검토할 필요가 있다는 점이 중요하게 다루어진다.